

1501821-74.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... com o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que, a liderança dos muitos dos pontos de tráfico de drogas da área onde foi realizada a apreensão da droga é exercida pelo membro da facção criminosa "PCC", conhecido por "Feijão", e o denunciado, de vulgos "Boladão" ou "Kaxeta SB" era o atual "gerente" de "Feijão". O denunciado era responsável por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501821-74.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501821-74.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 170/2021 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 2144615//21 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON ROGERIO TELASCREA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

EMERSON ROGÉRIO TELASCREA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso na prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 27 de maio de 2021, na Rua Oito, 26, Favela Pantanal, Saboó, Santos, o denunciado adquiriu e trazia consigo, para fins de comercialização, drogas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, em data indeterminada, mas seguramente antes do dia 27 de maio de 2021, em Santos, o denunciado e "Feijão", de qualificação ainda desconhecida, associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que, a liderança dos muitos dos pontos de tráfico de drogas da área onde foi realizada a apreensão da droga é exercida pelo membro da facção criminosa "PCC", conhecido por "Feijão", e o denunciado, de vulgos "Boladão" ou "Kaxeta SB" era o atual "gerente" de "Feijão". O denunciado era responsável por administrar a contabilidade e prover o abastecimento das biqueiras, e fazia uso de uma casa na comunidade para tal fim (a mesma em que foram apreendidas as drogas ora objeto de denúncia).

A denúncia narra que, na primeira tentativa de prender o denunciado, em data

anterior ao dia do flagrante (abril/2021), os policiais avistaram um indivíduo com as características do ora denunciado saindo de uma casa, o qual se evadiu ao ver os policiais. Nessa referida casa, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas e diversos outros objetos ligados à traficância.

Deste modo, os policiais arregimentaram outras equipes para, novamente, tentar prender o denunciado. No dia dos fatos, os policiais surpreenderam o denunciado saindo da residência juntamente com terceira pessoa, portando um rádio comunicador, e conseguiram detê-lo.

Já dentro do imóvel, foram encontradas diversas porções de drogas, cocaína já embalada, um tablete de maconha, vários tubos com loló, tubos vazios, pinos de eppendorf, balança de precisão, saquinhos plásticos, rolos de papel filme, rádio comunicador, muitas anotações de contabilidade de pontos de tráfico de drogas, um simulacro de pistola na cor preta, R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), além de documentos que ligam o denunciado à residência.

Por fim, consta que, a divisão de tarefas verificada pela investigação – o denunciado era o responsável por administrar a contabilidade e prover o abastecimento dos pontos de tráfico, sendo que fazia uso de uma casa na comunidade para tal fim; e “Feijão”, membro da facção criminosa “PCC”, o qual exerce a liderança dos muitos dos pontos de tráfico de drogas da área onde foi realizada a apreensão da droga – demonstra que ambos estavam associados para a realização do comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 03/08). Auto de exibição e apreensão (fl. 15/18). Relatório final (fls. 111/114). Laudos de exame químico-toxicológico (fls. 146/149 e 150/153). Laudo pericial das anotações apreendidas (fls. 154/167).

O réu foi notificado (fls. 172), e apresentou defesa prévia (fls. 173/186).

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fls. 196/199), e o réu foi citado (fls. 240).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas quatro testemunhas, e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu, primeiramente, o aditamento da denúncia apenas para esclarecer que o líquido apreendido na residência do acusado, trata-se de cloreto de metileno/diclorometano. No mérito, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Afirmou que os testemunhas policiais esclareceram as diligências realizadas que levaram à prisão do réu. Ambas relataram que dentro da residência do acusado foi encontrada droga e rádios para comunicação, comumente usados por traficantes. Aduziu que a prova documental de fls. 156/165, trata de contabilidade do tráfico de drogas. Quanto ao depoimento da testemunha Priscila, destacou que ela é esposa do acusado, portanto, possui interesse na sua absolvição. Já Valdecir, é usuário de drogas, e a versão apresentada por ele não é crível.

Ademais, destacou que o réu não esclareceu a posse das drogas encontradas em sua residência e que, o delito de associação para a prática do tráfico ficou caracterizado, pois não o acusado não poderia vender entorpecentes sem a autorização da organização criminosa e, ainda, a posse dos rádios comunicadores demonstra que ele estava integrado à organização. Diante da quantidade de entorpecentes apreendida, ficou claro o objetivo de se realizar a venda do produto. Ao final, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena.

A D. Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal. Aduziu que a prova dos autos foi obtida de maneira ilícita sendo, ainda, bastante frágil para embasar a condenação do réu. A Defesa pontuou que, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, ficou firmada jurisprudência de que a inviolabilidade de domicílio só poderá ser mitigada por fundadas razões antecedente a esta incursão no imóvel alheio. Portanto, sendo a prova obtida nos autos, ilícita, de rigor a absolvição do acusado. Quanto ao mérito, aduziu que as provas não foram suficientemente capazes de fomentar a condenação pretendida pelo Ministério Público. Alegou que houve contradições insanáveis nos depoimentos policiais e que a detenção e entrada na residência do réu foi feita sem a autorização de um mandado de busca e apreensão. Ademais, a testemunha Valdecir negou ter visto o encontro de

drogas e relatou que viu um policial com uma mochila. Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, disse que não ficou comprovado estar o réu associado a mais uma pessoa, tendo em vista que não ficou devidamente demonstrada a ligação entre o réu e o investigado "Feijão", havendo apenas uma denúncia anônima que não pode embasar o decreto condenatório. Assim, diante da ilicitude das provas e de sua fragilidade, é imperiosa a absolvição do acusado. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a fixação da pena pelo delito de tráfico, no mínimo legal, e, na última fase, que seja diminuída a pena no máximo previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por não ter sido comprovado o envolvimento do acusado em organização para a prática de tráfico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, anoto que recebo o aditamento da denúncia, realizado quando das alegações finais, apenas para esclarecer que o líquido apreendido na residência do acusado, trata-se de cloreto de metileno/diclorometano.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação criminosa para a prática de tráfico não restou adequadamente comprovada.

A testemunha MARCEL ALEXANDRE DA COSTA ROSA, policial civil, recordou-se do acusado. Contou que ele era conhecido como "Kaxeta SB" ou "Bolachão" da Rua 8. Ao realizarem investigações sobre a facção criminosa ao qual o réu integra, conseguiram mapear os locais após diversas diligências. Certa vez, viram o réu fumando maconha, mas ele saiu correndo para uma parte que fica atrás da casa, quando viu os policiais. Os policiais entraram na casa do réu, e lá foram encontrados entorpecentes, documentos de Priscila e do próprio réu. Após, mapearam as rotas de fuga do local, e notaram que elas desembocavam em um campo e em um mangue. Diante disso, montaram uma diligência para tentar pegar o réu em flagrante. Três equipes foram ao local para evitar uma nova fuga. Ao chegarem ao local, viram outro rapaz, um senhor mais velho, que conseguiu fugir em direção ao mangue. A testemunha Valdecir também foi abordada, e com ele foi encontrado em sua posse duas porções de maconha. O acusado foi abordado, e foram até a rua onde fica a casa dele. A chave da casa estava na porta. Dentro do local conseguiram encontrar 20 tubos de loló, pouca quantidade de cocaína (cerca de 10 gramas divididas em eppendorfs), maconha separada em tablete (cerca de meio quilo). Ademais, foram encontrados diversos documentos que foram remetidos para perícia, três rádios HT comunicadores. A testemunha narrou que parte da droga foi encontrada em um local que parecia um banheiro, em cima de um estofado. Outra parte dos itens foi encontrada em um forro, sob uma escada, que vai para a parte dos fundos da casa. A respeito das anotações, informou que elas indicavam movimentação do tráfico, havia valores pequenos e nomes que se repetiam, como se fossem turnos de venda. Contou que "Feijão" é um integrante da facção criminosa responsável pela região. Apontou que todas as denúncias que receberam, apontavam que o réu era gerente de "Feijão", e que ele trabalhava gerenciando as biqueiras. Afirmou que chegaram à essa conclusão, por conta das denúncias, das diligências realizadas, e das apreensões feitas. A testemunha relatou que, na denúncia que receberam, veio a informação da gerência do réu, dizendo que "Bolachão/Boladão" era responsável pela gerência, mas não havia informação de outra pessoa envolvida. Quando foram a primeira vez na casa do réu, encontraram fotografias com o nome dele e um quadro de futebol que continha o seu vulgo. O vulgo informado na denúncia era "Boladão" ou "Kaxeta". O acusado foi acompanhado por cerca de seis meses. Verificaram que ele gerenciava a região do final do Saboó, na Vila Pantanal, redondezas da Rua 8, mas não soube dizer por quantas biqueiras ele era responsável. A equipe conseguiu averiguar que o réu utilizava a casa para armazenar drogas. Quando detido, o réu negou o tráfico, dizendo que somente estava fumando maconha. A testemunha Valdecir acompanhou as buscas na residência do acusado. A testemunha contou que, como não havia como se realizar campana no local, as investigações se basearam nas denúncias anônimas. Afirmou que não havia mandado de busca e apreensão para entrar na residência, mas que entraram no local mesmo assim, diante da situação que presenciaram. Ademais, a chave da casa estava na porta.

A testemunha VALDECIR DA SILVA RODRIGUES contou que o réu trabalha como ajudante geral e que é usuários de entorpecentes. Relatou que viu a polícia entrando na residência do acusado. Afirmou que foi detido com maconha, e que a polícia o forçou a entrar na residência do acusado. Enquanto estava lá, os policiais começaram a revirar tudo, depois chegou outra equipe na qual havia um policial com uma mochila bem grande nas costas. Os policiais continuaram as buscas, mas nada foi encontrado na casa do acusado. Relatou que uma equipe foi fazer buscas no mato, e que permaneceu na sala durante esse procedimento. Ao final, disse que não foi apresentado nenhum documento autorizando a entrada na residência, assim como que não viu o que havia na mochila que o policial trazia consigo.

A testemunha PRISCILA DANIELLE DOS SANTOS, companheira do acusado, afirmou que o Emerson já havia saído de casa para trabalhar, e que voltou à residência para pegar objetos seus, quando viu os policiais vindo. Relatou que um senhor (Valdecir) deixou cair uma trouxa de maconha e, então, ele foi abordado. Este mesmo senhor foi colocado dentro de sua casa, diante disso, voltou para a casa da sua mãe. Ao retornar, este senhor ainda estava dentro de sua residência, e o seu marido (o acusado) estava dentro de uma viatura. Afirmou que o seu marido apenas possuía um "baseado", e que não tinha nada na residência deles. Contou que Emerson é ajudante de pedreiro, e que estava trabalhando em São Vicente. Negou que tenha sido apresentado algum mandado de busca e apreensão, e que a porta de sua casa estava trancada, mas os policiais a arrebentaram para poder entrar no local. Ao final, confirmou que o Emerson tem o apelido de "Kaxeta".

A testemunha LUCAS BITTAR, policial civil, disse que a Delegacia de Investigações Gerais realiza diversas diligências na Favela Pantanal, em razão de tráfico de drogas na região. A testemunha relatou que, dois meses antes da prisão do réu, a delegacia recebeu uma denúncia anônima que dava conta que o réu, vulgo "Boladão" ou "Kaxeta", estaria realizando a função de gerência do tráfico de drogas no local. Souberam que o réu usava a casa para guardar entorpecentes. Antes do dia que culminou na prisão do réu, a testemunha relatou que foram até o local dos fatos, andaram até o fundo da favela, e conseguiu observar o acusado, tanto que viu a sua tatuagem no peito. Porém, após dada ordem de parada, o réu se evadiu por dentro da casa, e saiu pela janela. Disse que a rota utilizada por ele, provavelmente, era uma rota de fuga, e acabaram por perdê-lo de vista. Contudo, conseguiram entrar na casa, e lá dentro encontraram diversos tipos de drogas: cocaína, loló, maconha, e anotações relativas ao tráfico. Diante dos fatos, continuaram realizando diligências no local, e obtiveram a informação de que o réu continuava a exercer a função de gerência de drogas, por conta disso, decidiram realizar mais uma incursão pela favela. No dia do flagrante, foram com mais duas equipes ao local, sendo que uma foi por um lado da favela, e as outras duas seguiram em outras direções, para tentar interceptar o acusado, no caso de tentativa de fuga. Neste dia, viram o réu com mais um indivíduo, na porta da casa alvo. O acusado conseguiu fugir, mas conseguiram efetuar a abordagem do rapaz que estava com ele (Valdecir). Com esse rapaz foram encontradas duas porções de maconha. Outra equipe que estava nos fundos da favela, conseguiu deter o réu. Nada de ilícito foi encontrado com o réu, apenas um rádio HT. O acusado foi trazido até a residência, então as equipes, ele e a testemunha abordada adentraram ao local. Novamente foi localizado loló, maconha, cocaína, um simulacro de arma de fogo e anotações com movimentos, valores e nomes, típico do tráfico de drogas. Contou que trabalha na DIG há dois anos, e que tem conhecimento de que dois indivíduos, vulgos "Feijão" e "Mimi", controlam o tráfico na Favela Pantanal. Constou das diligências que, em razão da prisão de "Mimi", o acusado gerenciava um maior número de ponto de venda de drogas. Disse que as apurações foram, basicamente, denúncias anônimas e as duas diligências de campo. No momento em que foi detido, o réu negou a posse das drogas, e disse que residia no local a cerca de 2 ou 3 semanas. Contou que a ligação entre a denúncia anônima e a identificação do réu se deu por conta do encontro de um quadro, onde havia o nome do acusado. Afirmou que o rapaz abordado (Valdecir) presenciou o encontro das drogas e do simulacro. A testemunha contou que, da primeira denúncia anônima, até a primeira incursão, demorou menos de cinco meses; e da primeira entrada na Favela, até a segunda, cerca de dois meses. Contou que como não tinham a qualificação do

réu, e por ser a região de difícil acesso, não conseguiram fazer campana, pois corriam o risco de confronto. Pela mesma razão, não pediram à Justiça a expedição de mandado judicial de busca e apreensão. A denúncia anônima dava conta de que havia uma “casa bomba”, no final da Favela do Pantanal, e que era o réu quem gerenciava parte do tráfico, guardando drogas e fazendo a contabilidade, tudo nesta residência; além do que, noticiava que o responsável tinha uma tatuagem no pescoço e no peito. A testemunha contou que na primeira vez, que entraram na residência, encontraram um documento com o nome da esposa do réu; na segunda, encontraram documentos com o nome dele. Afirmou que, fora a denúncia de que ele trabalhava com o vulgo “Feijão”, não há ligação concreta entre eles. Entretanto, disse que, para gerenciar uma biqueira naquele local, tem que ter autorização do partido (PCC), e quem manda na região são “Feijão” e “Mimi”. Não soube dizer se o réu foi preso novamente e afirmou que não o conhecia antes dos fatos.

O réu EMERSON ROGÉRIO TELASCREA, interrogado, negou os fatos. Disse que no dia do ocorrido estava saindo para trabalhar. Contou que ao lado da sua casa, existe um acesso que todos os moradores utilizam para chegar ao ponto de ônibus. Falou que um carro preto parou na “pista”, e que de dentro dele saiu um policial, que lhe apontou uma arma. Continuou caminhando até o ponto de ônibus, até o policial dizer que estava sendo detido, pois estava em um local usado para fuga de traficantes. Em razão disso, foi algemado, e o policial disse que seria levado para averiguação, mas para ficar calmo, porque nada havia sido encontrado com ele. Falou que havia duas viaturas do GOE na comunidade, e que depois de meia hora, policiais vieram conduzindo Valdecir, com as drogas na mão e um cooler. Já na delegacia de polícia, foi informado que Valdecir tinha dito que as drogas eram suas. Negou que conhecesse os policiais. Confirmou que já viu a prática do tráfico no local onde foi detido, mas nunca ouviu falar de “Feijão”. Disse que os policiais não apresentaram nenhum mandado para entrar em sua residência. O réu disse que estava saindo para trabalhar, e que trajava as suas roupas normais, não sabendo dizer como os policiais o identificaram por suas tatuagens. Disse não saber se alguém queria incriminá-lo, pois mora há pouco tempo no local e não fica muito na comunidade. Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Em que pese a declaração das testemunhas policiais de que a diligência, que culminou com a prisão do acusado, foi precedida de investigação para o combate ao crime de tráfico de drogas, nada dessa investigação veio aos autos.

De nada adianta o trabalho investigativo se ele não vier documentado para os autos do processo. O que se tem no presente caso é o flagrante delito e as declarações das partes sobre o ocorrido. Não há nenhum documento, nem mesmo um relatório sobre o recebimento das denúncias anônimas, e das diligências realizadas.

Não se sabe, por exemplo, como os policiais identificaram o acusado, nem mesmo como descobriram seus apelidos, a mera alegação de que foi por meio de denúncia anônima, sem mais nenhuma prova, não é suficiente para explicar a descoberta.

Também não ficou claro nos autos, como os policiais conseguiram identificar a “casa bomba”, pois eles apenas disseram de forma genérica e sem maiores esclarecimentos que, após diligências, identificaram o local que estava sendo usado como centro de operações do tráfico.

Além disso, se o acusado, de fato, ocupa posição de destaque na organização criminosa, como declarado pelos policiais, não é crível que o trabalho de investigação não tenha resultado na obtenção de qualquer número de telefone, que pudesse permitir a realização de interceptações. Justamente para comprovar a sua posição de gerência na organização criminosa, e possibilitar a identificação de outros membros da organização criminosa, permitindo, até mesmo, a prisão de mais pessoas responsáveis pela prática delituosa na comunidade.

Quanto às anotações do tráfico apreendidas, consta do laudo pericial juntado as fls. 155/165 que era necessário se colher material grafotécnico com o acusado de modo a permitir a comparação e, isso não foi feito. Razão pela qual, as anotações não se mostram aptas a provar nada em desfavor ao acusado.

Não se pode perder de vista, ainda, que a busca e apreensão realizada no dia da prisão em flagrante do acusado, foi realizada sem qualquer ordem judicial.

A busca e apreensão domiciliar é regida, constitucionalmente, pelo disposto no

artigo 5º, inciso XI, da CF/88, que dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O primeiro ponto a se analisar, portanto, é a hipótese de ingresso “com consentimento do morador” e, para tanto esse consentimento deve ser válido e expressado de maneira livre.

Guilherme Madeira Dezem bem destaca: “O consentimento do morador deve ser analisado com cautela. Assim, por se tratar de exceção constitucional precisamos lembrar que a qualquer tempo poderá ser retirado o consentimento. (...) De nada adianta a Constituição Federal erigir um castelo em torno do domicílio, se este castelo pode ser aberto de qualquer forma, pois seus portões são de papelão” (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 834).

Na mesma linha, o E. Min. Rogério Schietti Cruz bem destacou: “O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: 'O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!’” (STJ, T6, HC 598051/SP, DJE 02.03.21).

Do depoimento das testemunhas Valdecir e Priscila, é possível verificar que não houve o consentimento do morador (o réu ou sua esposa Priscila), para que houvesse a entrada dos policiais no imóvel.

O acusado, em seu interrogatório, somente disse que os policiais o detiveram, o colocaram em uma viatura, e depois vieram com a testemunha Valdecir, portando um cooler. Ora, ao que tudo indica, ele nem tinha conhecimento de que os policiais haviam entrado em sua residência, quanto mais que tenha dado consentimento para tanto.

O policial Marcel justificou a entrada na casa do acusado dizendo que a chave do local estava na porta. A testemunha Lucas também não disse se houve o consentimento explícito ou não de qualquer morador do local para a entrada na residência.

Nesse raciocínio, comporta verificar que, diante da controvérsia em relação à autorização do morador (no caso o acusado ou sua esposa) para o ingresso dos policiais em seu domicílio, deve vigorar o princípio do in dubio pro reo, ou seja, considerando que o acusado não é obrigado a produzir prova contra si próprio, não é crível que sendo ele o gerente do tráfico de uma grande organização criminosa (como alegado pelos policiais), e possuindo no local drogas e anotações do tráfico, iria permitir o ingresso dos policiais em sua moradia de livre e espontânea vontade.

E, segundo julgado do E. STJ (HC 598051/SP), o ônus da prova da legalidade da entrada no domicílio é do Estado.

No mesmo sentido as lições de Renato Brasileiro de Lima: “Para validar o ingresso de agentes estatais no interior da casa e subsequente busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Na visão dos Tribunais Superiores, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. (...) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade (...).” (Manual de Processo Penal, Editora JusPodium, 10ªed., p. 696).

Portanto, considerando a inexistência de qualquer comprovação da autorização do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência e, diante da versão por ele apresentada, a partir daqui se analisa o flagrante, considerando que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado ocorreu sem a permissão dele e, por conta disso, deve ser analisado a situação do flagrante de crime permanente, pois, no caso, o crime de tráfico de drogas se protraíu no tempo, ou seja, a ofensa ao bem jurídico protegido remanesceu durante todo o período de tempo em que as drogas e anotações

permaneceram no imóvel do acusado.

Passa-se, assim, a analisar a busca e apreensão sem o mandado judicial e sem autorização do acusado para o ingresso na sua residência, mas sob a alegação de se estar diante da segunda hipótese de permissão constitucional, cabível no caso em concreto, para a violação do domicílio, qual seja, o de flagrante delito.

E, sob esse aspecto, tem-se que a medida também se mostrou ilegal.

No caso sob análise, segundo os policiais, aproximadamente dois meses antes da prisão do acusado, a equipe já havia realizado operação no local, em razão de denúncia anônima de tráfico de drogas, dando conta da localização da “casa bomba” (imóvel utilizado para guarda do entorpecente), apontando o acusado como responsável pelo tráfico e informando, inclusive, os seus apelidos.

Todavia, na citada operação, embora os policiais tenham conseguido identificar a referida “casa bomba”, e nela apreender grande quantidade de entorpecente, o acusado e seus comparsas conseguiram fugir. E, foi por isso, que cerca de dois meses depois, três equipes de policiais civis voltaram ao local com o intuito de prender o acusado.

Entretanto, pela narrativa prestada pelas testemunhas policiais, não ficou clara a motivação da nova entrada no domicílio do réu, pois apesar de em outro momento terem sido apreendidos entorpecentes na residência do acusado, não havia nenhuma informação atual de que, naquele momento, ele estivesse em flagrante delito.

Logo, não se pode falar que havia indícios concretos da prática do crime por parte do suspeito, por não ficar comprovado, com o mínimo de respaldo, qualquer atitude que possa vir a justificar a entrada no domicílio sem autorização judicial, e sem o consentimento dos moradores que lá residem.

Sobre a matéria o C. STF já pacificou: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Essa a orientação do Plenário, que reconheceu a repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia, à luz do art. 5º, XI, LV, LVI, da CF/1988, a legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado de busca e apreensão” (STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).

Analisando a situação, Guilherme Madeira Dezem pondera: “O problema reside na análise dos motivos que levaram à entrada do domicílio sem mandado. Não se pode fazer aqui o raciocínio do resultado para a ação desenvolvida, valendo-se do resultado como legitimador da conduta. Esse raciocínio pernicioso põe ao chão a proteção constitucional do domicílio.” (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 836). Portanto, o fato de ter sido localizado algo ilícito e que configura crime permanente no domicílio não significa, necessariamente, que a conduta desenvolvida pelos agentes foi correta. Do mesmo modo que, não localizar nada não significa que a conduta dos policiais venha ser ilegal.

Destaca o citado doutrinador: “O que precisará ser feito pelo Poder Judiciário é ignorar o resultado e analisar os motivos dados pelos agentes para a entrada no domicílio, somente assim teremos a análise concreta dos motivos que ensejaram a entrada no domicílio e poderá haver o concreto controle judicial” (Dezem, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p.836).

No mais, outro ponto a ser analisado, é o fato de que a Autoridade Policial, mesmo em posse de informações obtidas na denúncia anônima, na primeira diligência, não representou pela expedição de mandado de busca e apreensão.

A justificativa apresentada por pelos policiais, ouvidos em Juízo, no sentido de não realizarem o pedido de forma correta, é muito vaga. Além disso, eles se justificaram partindo do pressuposto de que, não sendo possível fazer campana, não se conseguiria o mandado de busca e apreensão.

Todavia, para evitar macular as suas ações, os agentes não podem partir de suposições, o correto seria angariar o máximo de informações possíveis, pelos meios que a polícia civil dispõe, incluindo aí as denúncias anônimas, verificação em bancos de dados, e os mesmos meios utilizados para identificar a “casa bomba”, e

suas rotas de fuga, para proceder à representação pela expedição do mandado judicial.

Inclusive, a impossibilidade de campana e fotografação do local, por conta da configuração da comunidade, e por colocar a vida de policiais em risco, poderia ser mais um dos elementos apontados pela Autoridade Policial, a justificar a necessidade de um mandado de busca e apreensão, para que fosse possível a colheita de maiores evidências da prática de crimes.

Ora, se em outro momento houve encontro de droga, se os policiais possuíam informações mínimas sobre a identificação do acusado e se, com base nas denúncias anônimas, tinha-se o conhecimento de que ele era um gerente do tráfico, não há justificativa plausível para que não fosse requerido o mandado de busca e apreensão ou, até mesmo, o pedido de interceptação telefônica, haja vista se ter notícia de sua ligação com o traficante de vulgo “Feijão”, pessoa já conhecia no meio policial e que já vem sendo investigado, conforme informado pelos policiais.

Ocorre que, como já dito, nenhuma outra prova de investigação veio aos autos de modo a comprovar as alegações e justificar a impossibilidade de se obter o devido mandado judicial de busca e apreensão.

Ainda que se possa compreender certas dificuldades na operação de campo, não se pode admitir como válida a operação, se nenhum elemento de convicção é trazido aos autos de modo a dar concretude a investigação e suspeitas de autoria.

Diante de todo o exposto, concluo que o conjunto probatório se torna extremamente frágil e inconsistente, pois, em nenhum momento, restou seguramente demonstrada a autoria delitiva por parte do réu.

É imperioso observar que para uma condenação exige-se prova séria acerca da materialidade e autoria, o que não se infere dos autos.

Nesse contexto, não há como se editar um decreto condenatório contra o acusado pelos crimes em comento, uma vez que o contexto probatório se mostra extremamente frágil.

No mais, é cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, devem existir nos autos, provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário, deverá incidir o princípio do in dubio pro reo.

Neste desiderato, a dúvida sempre beneficia o acusado, uma vez que a condenação exige certeza e o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação.

Assim sendo, imperiosa se faz, em um Estado Democrático de Direito, que tem por um de seus pilares o direito fundamental à liberdade, a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para ABSOLVER o acusado EMERSON ROGÉRIO TELASCREA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro ao réu o direito de aguardar decisão de eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos na forma da lei.

P.I.C.

Santos, 11 de março de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA